

04/12/2003

Cám. Civ. y Com. de 2ª Nom. (Córdoba)

Sentencia 111

Renzi Pedro Celestino c/ Soda Renzi S.R.L. y Otros – Societ. Contenc. y Coop.- Impugnación de Asamblea.

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión

La Sra. Vocal Dra. Silvana María Chiapero de Bas, dijo:

1) Contra la Sentencia número Cuarenta y Cuatro dictada con fecha Tres de Marzo de Dos Mil Tres por la Sra. Juez de 39ª Nominación, interpuso el Actor recurso de apelación que fue concedido por el a quo (fs. 119/120). Radicados los autos en esta Sede, expresa agravios el apelante (fs. 123/135 vta.) dándose por decaído el derecho dejado de usar por la contraria (fs. 137 vta.). Dictado y consentido el proveído de autos y la integración del Tribunal, queda la causa en estado de estudio y resolución.

2) Pedro Celestino Renzi promueve demanda de impugnación de la asamblea (reunión de socios) celebrada el Treinta de Mayo de Dos Mil Dos, en contra de la sociedad Sodas Renzi S.R.L. y de sus socios Oscar Castro, María Luisa Heisecke de Fabiano, Clara Mónica Fabiano, Silvia Claudia Fabiano, Luisa Alejandra Fabiano y Héctor Fabián Fabiano, la que fue rechazada por la primer Juez, imponiéndole las costas al Actor vencido.

3) El apelante fustiga el decisorio –en prieta síntesis- por lo siguiente: a) por cuanto rechazó la demanda contra los socios, pese a que la promovida en su contra no fue admitida ni sustanciada; b) por cuanto entiende que el acto impugnado adoptó la forma de “declaración escrita de todos los socios” desoyendo lo que realmente aconteció: la celebración de una verdadera asamblea de socios. Sostiene que la Ley Societaria (art. 159 L.S. modificada por Ley 22.093) en modo alguno prohíbe las asambleas, siendo plenamente válida la previsión estatutaria que disponga que las decisiones deberán adoptarse en asambleas, como tampoco veda que los socios decidan que determinada cuestión sea decidida en asamblea; c) por cuanto se desestiman los vicios de la convocatoria de la asamblea con los argumentos de que no es necesaria la observancia del procedimiento previsto en el art. 237 L.S. y que no se habría demostrado el agravio, los que no son verdaderos porque el art. 159 L.S. remite al art. 236 conforme al cual las asambleas solo pueden ser convocadas por el gerente o el consejo de vigilancia o cuando sea requerida por los socios que representen no menos del

cinco por ciento del capital social pero siempre a través del órgano social. Además los herederos de Héctor Fabiano al momento de celebrarse la asamblea no revestían el carácter de socios mayoritarios del capital social porque no resultaron adquirentes de las cuotas sociales de Oscar Castro y porque de los propios términos de la Sentencia surge que Pedro Renzi tiene 968 cuotas sociales en tanto que los restantes socios sólo 605 cuotas.; d) por cuanto desestima el vicio relativo a la temporalidad de la convocatoria sin considerar que es de toda lógica que todo socio conozca con cierta antelación a la celebración de la asamblea, los temas a tratar en su seno, de modo que ninguna razón se ha esgrimido para no cumplir con las previsiones del art. 237 L.S. que resulta aplicable por remisión del art. 159 3º párrafo.; e) por cuanto se sostiene el principio de libre revocabilidad de los gerentes por decisión de la mayoría del capital presente, sin advertir que: en el caso se optó por la remoción con causa que importaba cumplir con todas las exigencias que este tipo de revocación exige; f) por cuanto la supuesta cesión de cuotas entre el socio Castro y los herederos del ex socio Héctor Fabiano no debió merecer tratamiento porque jamás se notificó la cesión de tales cuotas sociales.

4) El nominado como primer agravio no reviste tal carácter ya que no se vislumbra cuál es el perjuicio que ocasiona al Actor el decisorio en cuanto desestima la demanda en contra de los socios demandados.

Si el propio impugnante admite la corrección del argumento sentencial en que se funda el rechazo de la acción contra los socios (arts. 251 y 248 L.S.C.), no se advierte cuál es el interés por modificarlo, máxime cuando no ha mediado actividad procesal de los socios que pudiera acrecentar las costas causídicas que debe soportar el apelante por la desestimación de esta demanda.

Sin daño concreto que aliente el recurso, la apelación deviene formalmente inadmisibile.

Los restantes agravios no logran conmover los escuetos pero medulosos argumentos vertidos por la primer Juez en sustento del rechazo de la demanda impugnativa.-

En el régimen de resoluciones sociales introducido por la Ley 22.903, la asamblea dejó de ser el modo supletorio genérico para los acuerdos sociales, como sucedía en el sistema legal anteriormente vigente.

Con las reformas introducidas por la mentada Ley al art. 159 L.S. queda patentizado que el legislador ha considerado más acorde con el tipo societario admitir, en subsidio de estipulaciones sociales específicas, formas más sencillas para las decisiones de los cuotistas, como son las consultas a los socios (según era ya tradicional en esas sociedades) o la declaración escrita del voto de todos los socios como aceptaba la ley alemana.

Así el régimen legal vigente en punto a la forma de deliberación de una sociedad del tipo de la demandada (S.R.L.) es el siguiente: a) como principio general lo que haya dispuesto el contrato social; b) en defecto de previsión contractual "...se consideran válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los 10 días de haberseles cursado nota simultánea a través de medio fehaciente; o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto" (Verón "Sociedades Comerciales - Ley 19.550. Actualización Leyes 22.903 y 22.985" Editorial Astrea, p. 380).

Es cierto que la directiva legal no prohíbe que el contrato disponga que la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales sea la asamblea, pues justamente el primer párrafo autoriza a los socios a decidir libremente, consagrando las restantes formas sólo en forma subsidiaria, esto es en defecto de previsión contractual expresa.

Pero, como bien lo destaca la Magistrada, en el contrato constitutivo de Sodas Renzi S.R.L. ni en ninguna modificación social ulterior, se previó estipulación contractual alguna respecto del gobierno de la sociedad, por lo que rigen en plenitud las dos formas consagradas en el segundo párrafo del art. 159 L.S..

También lleva la razón el apelante cuando sostiene que tampoco está prohibido que -aún en defecto de previsión contractual expresa- los socios deliberen en asamblea. Sin embargo yerra cuando hace derivar de ello la ineficacia de la decisión adoptada en declaración escrita por la totalidad de los socios el Treinta de Mayo de Dos Mil Dos.-

En primer lugar, porque la sola circunstancia de que en la C.D. por la que se comunica la realización de la reunión de socios se haya hecho alusión a asamblea, no es suficiente fundamento para concluir que fue la intención de los socios celebrar una asamblea con todas las formalidades previstas para su realización.

Pero, lo que es más radical, si el legislador ha ponderado que son eficaces las resoluciones sociales adoptadas mediante una forma más sencilla de deliberación, lógico resulta colegir que no resulte menester que se encuentren reunidas las formalidades previstas para otras formas de deliberación más compleja.

Tampoco es cierta la pretendida aplicabilidad a la especie del régimen de los arts. 236 y 237 L.S. porque la remisión que efectúa el art. 159 L.S. está referida a las asambleas a las que se refiere la primera parte del segundo párrafo (sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299 inc. 2º) supuesto que no es el de autos.

Pero si lo expuesto hasta aquí fuera insuficiente, cabe agregar que el impugnante sigue sin demostrar el agravio o perjuicio concreto que la falta de antelación en la notificación de la

convocatoria pudo haberle ocasionado, máxime si se repara que han estado presentes todos los socios de modo que todos han podido ejercer igualmente sus derechos sociales.

Despejada la cuestión respecto de la validez de la forma deliberativa utilizada por los socios de Sodas Renzi S.R.L. para decidir la remoción y la innecesariedad de cumplir con todas las formalidades previstas por la L.S.C. para la celebración de asambleas, la inconducencia de los restantes agravios relacionados con las personas legitimadas para convocar asambleas, luce palmaria.

Si en el sistema de la Ley y el Estatuto las decisiones sociales pudieron adoptarse con la declaración escrita en las que todos sus socios hayan expresado el sentido de su voto, el incumplimiento de las formalidades previstas para la forma de deliberación más compleja (asamblea) no puede acarrear la pérdida de eficacia de la decisión adoptada.

Tampoco es de recibo el agravio relativo a los requisitos que deben reunirse para decidir la remoción de un gerente en el tipo de sociedad que adoptó la demandada.-

La L.S.C. ha consagrado el principio de la libre revocabilidad de los gerentes, al declarar en el cuarto párrafo del art. 157 L.S.C. que ésta no puede limitarse a excepción que "...la designación fuere condición expresa de la constitución de la sociedad", único supuesto es que se requiere justa causa de remoción.

Es decir que, en el sistema diseñado por el legislador societario para este tipo de sociedad, el administrador puede ser removido sin invocación de causa ("ad nutum"), esto es sin que se encuentre subordinado a la concurrencia de causa legítima (Halperín - Sociedades de Responsabilidad Limitada, p. 189).

El acto de remoción es un acto unilateral de la sociedad y el gerente, aunque tenga derecho de intervenir y oponerse a la votación, no puede oponerse a la revocación de su designación con fundamento en la inexistencia de causa grave o suficiente para ello, ya que permitirlo importaría desnaturalizar el sistema de revocación "ad nutum".

Esto es así, sin perjuicio, claro está, del eventual derecho a reclamar el resarcimiento del daño ocasionado en caso de que pudiera acreditarse la inexistencia de causa que justifique la revocación, cuestión que no corresponde tratar en esta ocasión por exceder el límite de la litis (Verón, opus cit. pag. 964).

El agravio relativo a la supuesta ausencia de mayoría está fundado en dos argumentos igualmente inconducentes.

Con el primero el apelante fustiga que la primer Juez se haya detenido a dilucidar si la ausencia de inscripción de la cesión de cuotas del socio Castro a los herederos de Héctor Fabiano la torna oponible o no a los restantes socios, sin advertir que esa cuestión sería abstracta porque la cesión jamás habría sido notificada.

El quejoso no rebate expresos argumentos de la Magistrada mediante los cuales resaltó que mediante la C.D. Nº 448955042 A.R. se comunicó la adquisición por parte de los herederos de Fabiano de la totalidad de las cuotas partes que fueran propiedad del Sr. Castro.

Pero además, y lo que resulta más fundamental para contrarrestar este agravio, no se hace cargo del pasaje del fallo donde se destacó que "...Aún cuando se le dé o no validez a la cesión de cuotas efectuada entre el socio Castro a los socios Fabiano, ello no altera en modo alguno el sentido de la votación, pues la resolución fue adoptada con el voto favorable de la mayoría del capital social -605 votos- (242 + 363 votos)"; "...Si no se le otorga validez a la cesión notificada mediante C.Documento obrante a fs. 39 entre socios, en la asamblea de 30 de mayo de 2002 estaba presente el apoderado del socio Castro -poder que no ha sido controvertido- y en consecuencia la resolución fue adoptada por mayoría. Si se le otorga validez entre los socios a la cesión prementada, la resolución también habría sido adoptada por mayoría -pues los socios Fabiano- habrían de detentar la mayoría del capital social" (sic fs. 117/117 vta.).

El pasaje transcripto es harto elocuente en torno a la absoluta falta de incidencia de la prementada cesión de cuotas en la concurrencia de la mayoría legalmente establecida para la revocación "ad nutum" del gerente, aspecto del fallo que -en tanto no rebatido- permanece en pie en sustento de lo decidido.

Finalmente, el agravio introducido recién en esta Instancia en punto a la supuesta falta de mayoría del capital social por parte de los socios Fabiano y Castro, no resiste el análisis.

La tardía consideración del apelante encuentra sustento en el error material en que incurre la Sentenciante al reiterar (párrafo final de Considerando Sexto) la participación social correspondiente al Sr. Pedro Renzi (484 cuotas sociales), lo que lo lleva -recién en Alzada- a afirmar que es titular de 968 cuotas sociales, y por ende ostentaría la mayoría del capital social.

La crítica no puede recibirse primero porque el yerro material -reiteración de la cantidad de cuotas de las que es titular el Sr. Renzi- se puede comprobar con las propias constancias documentales a las que remite la primer Juez (modificaciones sociales de fs. 59 y 60/2).

Pero si ello fuera insuficiente, basta reparar en la conducta procesal del propio Actor, para advertir la inconducencia de esta tardía pretensión.

Nótese que si su participación en el capital social fuera la ahora pretendida (968 cuotas), no se podría comprender la razón por la cual no esgrimió su calidad de socio mayoritario en libelo inicial, ni se explica tampoco que se haya preocupado –a lo largo de todo el proceso– por cuestionar la supuesta cesión de cuotas del socio Castro a los socios Fabiano, si –con o sin ella– ya ostentaba la mayoría del capital social.

Tal conducta es harto reveladora de que si fuera verdadera la participación societaria que ahora esgrime, su estrategia procesal hubiera sido diversa a la empleada.

En suma, lo real es que el actor –ahora apelante– no puede pretender que un mero error sentencial pueda –por arte de magia– estar en la causa de una duplicación de cuotas sociales de las que resulta titular.

El Sr. Vocal Dr. Jorge Horacio Zinny, dijo: Que adhiere al voto y fundamentos explicitados por la Sra. Vocal preopinante, votando de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN

La Dra. Silvana María Chiapero de Bas, dijo: Corresponde: rechazar la apelación y confirmar la Sentencia apelada en todo cuanto decide, con costas al Actor atento su calidad de vencido (art. 130 C.P.C.). No fijar honorarios a favor del Dr. Carlos Schröder, sin perjuicio de su derecho (art. 25 contrario sensu C.A.).

El Sr. Vocal Dr. Jorge Horacio Zinny, dijo: Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Sra. Vocal preopinante, votando de la misma manera.

A mérito del resultado del Acuerdo que antecede, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 9.129/03 que modifica el art. 382 del C. de P.C.,

SE RESUELVE:

- I. Rechazar la apelación y confirmar la Sentencia apelada en todo cuanto decide.
- II. Imponer las costas al Actor atento su calidad de vencido (art. 130 C.P.C.).
- III. No fijar honorarios..., sin perjuicio de su derecho (art. 25 contrario sensu C.A.).

Protocolícese y bajen.

Fdo.: Chiapero de Bas - Zinny.